

1502952-66.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Jardim das Flores, cep 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital 1502952-66.2021.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502952-66.2021.8.26.0542

Controle: 2022/000021

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

MARCILIO EWERTHON NASCIMENTO DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

MARCÍLIO EWERTHON NASCIMENTO DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, em 21 de dezembro de 2021, na Rua João Bueno Valadão, 200, Helena Maria, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, trazia consigo: 162,12g de maconha e 10,26g de cocaína, ambas substâncias entorpecentes, capazes de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com normal legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, com a finalidade de coibir a comercialização de entorpecentes que ali ocorria, ocasião em que avistaram dois indivíduos em circunstância que julgaram suspeita, os quais tentaram se evadir com a aproximação da guarnição.

Durante a fuga, Marcílio Ewerthon dispensou a sacola que levava em mãos. Todavia, ambos foram alcançados e abordados, bem como a sacola apreendida.

Em revista pessoal, na posse de Marcílio Ewerthon, foi localizada a quantia de R\$ 83,50 em dinheiro. No interior da sacola por ele dispensada foram localizadas diversas porções de maconha e cocaína.

Em revista pessoal nada de ilícito foi localizado com Gustavo Próspero Marcondes de

Moraes, também abordado no local, tendo ele assumido ser usuário de entorpecentes. A denúncia foi ofertada e notificado Marcílio Ewerthon (fls. 96). Sobreveio a defesa preliminar (fls. 110/116) e, não havendo causas de sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (fls. 99/100). Marcílio Ewerthon foi citado (fls. 123/125).

Durante a instrução processual criminal foram ouvidas testemunhas (fls. 155/157) e interrogado o acusado (fls. 158).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 123).

Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotora de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Marcílio Ewerthon nos termos da denúncia (fls. 162/165).

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06 ou, ainda, pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (fls. 172/183).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

A materialidade delitiva consubstancia-se em auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9), laudo pericial de constatação (fls. 15/18), exame pericial químico-toxicológico (fls. 148/150), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 155/157).

Perante a D. Autoridade Policial, Marcílio Ewerthon negou a prática delitiva e que a droga fosse sua (fls. 5).

Em Juízo, novamente, negou a prática delitiva. Afirmou que, na data dos fatos, desceu da rua da sua casa e chamou Gustavo. Estavam fumando maconha sentados na frente de uma casa. A viatura subiu a rua e ficaram assustados. Foram abordados e nada apreendido com os dois. Nem estavam com dinheiro. Os policiais ordenaram que se sentassem, mas não aceitaram e então foram colocados na viatura. A droga não foi mostrada no local. Na Delegacia, os policiais apresentaram uma sacola. Estava tendo um churrasco próximo ao local da abordagem (fls. 158).

A negativa de Marcílio Ewerthon não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado desmerecendo, portanto, guarida.

A testemunha Gustavo narrou que uma viatura chegou e fez a abordagem. Foram colocados na parede. Os policiais procuraram algo e, depois, disseram que estavam presos e foram levados na viatura. Eles não apresentaram drogas no local, só na Delegacia. Não correram dos policiais. Foram abordados e eles já falaram para que ficassem na parede. Depois, determinaram que se sentassem, mas ficaram em pé. Os policiais estavam armados e não perguntaram se tinha passagem na polícia ou Infância (fls. 155).

A testemunha Policial Militar Jailson asseverou que, em patrulhamento de rotina na Rua João Bueno Valadão, avistaram dois indivíduos na calçada. Quando notaram a viatura, eles saíram em sentido contrário. Os dois foram abordados. Antes da abordagem, viu que um deles jogou uma sacola na rua. Enquanto seu parceiro fez a abordagem dessa pessoa, foi atrás da sacola que ele jogou. Na sacola havia entorpecente. Com o abordado só havia dinheiro trocado. Ele informou que estava usando drogas.

Foi Marcílio quem jogou a sacola. Questionado, Marcílio informou que só estava usando drogas com o amigo.

Quando avistou os dois rapazes, eles estavam andando em sentido à viatura. Quando viram a viatura, viraram para o sentido oposto. Quando ele se deparou com a viatura, ele ainda estava com a sacola e jogou depois. Não se recorda como era essa sacola, que era de plástico. A sacola foi arremessada ao lado da abordagem. Quem fez a busca pessoal foi seu parceiro. Não havia outras pessoas além dos dois abordados. Conduziram os dois indivíduos e no D.P. o outro que estava com o acusado ficou como testemunha. Esse outro indivíduo também informou que estava usando drogas com o amigo. Ele foi questionado se o acusado estava traficando, mas apenas

respondeu que estavam usando drogas. Chegou a mostrar a sacola para o acusado e perguntar por que jogou a sacola, mas ele só respondeu que estava usando a droga. Viu o momento no qual a sacola foi arremessada. A viatura estava a 50m do acusado quando viu ele jogar a sacola. A ocorrência se deu no período da noite (fls. 156). A testemunha Policial Militar Cleber declinou que estava com a equipe em patrulhamento de rotina no Bairro Helena Maria, Rua Valadão, conhecido ponto de entorpecente. Avistaram dois indivíduos próximos da viela. Eles se assustaram ao ver a viatura e correram em sentido contrário. Aumentaram a velocidade da viatura e um deles soltou uma sacola próximo de um veículo e foi abordado logo em seguida. Em revista pessoal houve apreensão de notas trocadas com Marcílio. Verificaram o objeto dispensado, uma sacola, que continha entorpecente.

Pelas vestimentas, quando ele dispensou a sacola, pode ver que foi o acusado que o fez. A viatura estava a aproximadamente 50m dos indivíduos quando eles correram. No local estavam somente o acusado e o outro indivíduo. Na via pública havia pessoas, mas distantes deles. Não se recorda de como era a sacola. Foi levado ao D.P. onde só foi apreendido o entorpecente. Visualizou quando o acusado dispensou a sacola e fez a abordagem dele em revista pessoal, fazendo a segurança e contenção dos dois. Foi seu parceiro quem fez a apreensão e revista da sacola. Quando eles foram abordados, foram colocados de costas para os policiais e na parede. Ambos abordados disseram que estavam fazendo uso de entorpecente e por isso tentaram fugir da abordagem. Não foi visualizado se eles estavam fumando cigarro, pela distância. Viu o acusado com a sacola e quando ele passou perto do veículo ele dispensou a mesma. Quando entrou na via, o acusado visualizou a viatura e correu em sentido contrário, se evadindo e dispensou a sacola (fls. 157).

Os testemunhos policiais demonstram a veracidade dos fatos, até porque responderam às indagações formuladas, apresentando as mesmas circunstâncias, tanto no aspecto principal quanto no secundário, quer na fase extrajudicial como em Juízo.

É cediço que o testemunho policial não é afetado, positiva ou negativamente, pela função que exerce. A condição funcional não confere ao seu testemunho maior força persuasória e nem o inquina de suspeição. O valor probante de sua versão é aferido pelo mérito e de acordo com o grau de confiabilidade segundo a harmonia das provas coligidas aos autos. Neste sentido, vasta é a jurisprudência proclamada pela suficiência, se coesos os testemunhos policiais, para embasar o édito condenatório.

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial" (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha afim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.).

As provas são uníssonas e coesas quanto à responsabilidade criminal de Marcílio Ewerthon. Ele avistou a viatura e tentou fuga, sendo que durante o trajeto dispensou uma sacola, o que foi visto pelos milicianos. Abordado, com ele havia dinheiro trocado. Na sacola que dispensou estava o entorpecente.

Para caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes dever-se-á atender à natureza e a quantidade da substância entorpecente, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação criminoso, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Seguindo essas variantes houve plena demonstração do animus de traficar, sendo

robusto o material cognitivo.

Ora, os elementos citados são suficientes e indicam que o material tóxico apreendido se destinava ao comércio ilícito.

Marcílio Ewerthon foi denunciado por trazer consigo substância entorpecente cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes dos agentes, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciem a atividade delituosa" (TJRJ - ApCrim 5.492 in Direito Concreto, v. 5, p. 191).

"Desimporta se o agente não chegou a vender o tóxico, pois trazer consigo, já é delito consumado, segundo uma das normas múltiplas que contém o art. 12 da lei respectiva" (TJRS - AC 68.305.178-3 - Rel. Milton dos Santos Martins - RJTJRS 107/59).

Com esta prova a respeito da finalidade de entrega do entorpecente a consumo de terceiros não há que se cogitar da desclassificação para o delito preconizado no artigo 28, da Lei 11.343/06. Anote-se que eventual condição de usuário não exclui a traficância. Vale ressaltar que a quantidade de entorpecente que Marcílio Ewerthon trazia consigo, 162,12g de maconha e 10,26g de cocaína, não é condizente com a condição de mero usuário.

Conclui-se, pois, pela procedência da ação penal e consequente condenação de Marcílio Ewerthon Nascimento de Carvalho por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não agiu com intensidade dolosa incomum para os delitos da espécie a justificar a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do autorizado pelo artigo 59, do Código Penal.

Faz jus à atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente relativamente menor à época dos fatos:

"Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade". (RJD 23/299)

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal. Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.

Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Félix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

É tecnicamente primário.

É pertinente a redução prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.887.511-SP, que fixou diretrizes acerca da consideração da quantidade e variedade de entorpecentes na dosimetria da pena.

"PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença"

(REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, tratando-se de agente primário, a redução deve se dar em seu grau máximo, ou seja, 2/3, conforme o preconizado pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Considerando os parâmetros acima e os demais critérios preconizados pelo artigo 59, do Código Penal, fixo, a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na base. Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do artigo 65, inciso I, do Código Penal, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não há outras atenuantes ou agravantes. Reconhecida a aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, calculados na base. Não há outras causas de diminuição ou de aumento.

À minguia de outras causas legais de alteração torno esta pena definitiva.

Em face do disposto no artigo 33, alínea c, do Código Penal e artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixo o regime inicial aberto. Por força da Resolução 5/2012 do Senado Federal, não havendo óbice, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade por igual prazo. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO MARCÍLIO EWERTHON NACIMENTO DE CARVALHO, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à Comunidade, por igual prazo, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Diante do quantum da reprimenda aplicada e da substituição levada a efeito, Marcílio Ewerthon poderá recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE de imediato o competente ALVARÁ de SOLTURA clausulado.

Nos termos do artigo 60, c.c. o artigo 63, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 125, do Código Penal, atendido ao requisito do artigo 126, do Código Penal, e a teor do artigo 127, do Código Penal, decreto o perdimento do numerário apreendido, dada sua origem ilícita.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente nos termos regimentais.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

Osasco, 21 de março de 2022.